



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2013.0000498235

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0001699-27.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STEPHAN SCHAFFER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto por Stephan Schaffer apenas para conceder o sursis pelo prazo de dois anos, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BRENO GUIMARÃES (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 21 de agosto de 2013.

PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001699-27.2010.8.26.0050
Comarca de São Paulo - Vara do Foro Central de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher
Apelante: Stephan Schafer
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Ana Lucia Pecorão Schafer
TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO Nº 12.530

EMENTA: Apelação – Lesão corporal – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade – Rejeitada – Absolvição – alegação de ausência de prova da materialidade e da autoria – impossibilidade – autoria e materialidades comprovadas pelas provas produzidas nos autos.

Substituição da carcerária por restritiva de direitos – impossibilidade

Concessão de sursis – Possibilidade.

Recurso parcialmente provido.

Vistos.

1 – Trata-se de apelação interposta por Stephan Schafer contra a r. sentença datada de 03 de agosto de 2012, prolatada pela MMª Juíza da Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Paulo, que o condenou às penas de 03 (três) meses de detenção, por infração ao artigo 129, § 9º, do Código Penal, a ser cumprida em



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

regime aberto (fls. 268/272).

Irresignada, postula a d. Defesa, preliminarmente, a anulação da ação penal desde a audiência preliminar a fim de que seja dada ao apelante a oportunidade de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95. No mérito, reclama a absolvição sustentando a ausência de provas tanto da materialidade quanto da autoria. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da carcerária por restritiva de direitos (fls. 290/308).

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou o acerto da decisão e pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 357/364).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 368/370).

Este, em síntese, é o relatório.

2 – Da Preliminar

A d. Defesa requer o reconhecimento da nulidade da ação penal, em razão de ausência de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

No entanto, razão não lhe assiste.

Consoante se observa dos autos, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal, cometido contra sua ex-esposa, aproveitando-se das relações domésticas, de modo que o respectivo trâmite processual se sujeita aos termos da Lei nº



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

11.340/2006.

A suspensão condicional do processo não é cabível nos casos de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, que expressamente afastou a possibilidade de incidência da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95).

Referida Lei, em seu art. 41, assim dispõe:

“Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995.”.

Assim, entendo que o afastamento dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher inclui os institutos da transação penal (art. 76) e da suspensão condicional do processo (art. 89), ambos da referida lei.

Em relação ao art. 41, da Lei Maria da Penha, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher não são de menor potencial ofensivo, pouco importando o quantum da pena, motivo pelo qual não se submetem ao disposto na Lei 9099/95. Embora severa, a disposição do art. 41, é constitucional. Em primeiro plano, porque o art. 98, I, da Constituição Federal, delegou a Lei a conceituação



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

de infração de menor potencial ofensivo e as hipóteses em que se admite a transação. Em segundo lugar, pelo fato de se valer do princípio da isonomia e na da igualdade literal, ou seja, deve-se tratar desigualmente os desiguais. Em terceiro prisma, esse é o resultado, em nosso ponto de vista, da má utilização pelo Judiciário, ao longo do tempo, de benefício criado pelo legislador. Em outros termos, tantas foram as transações feitas, fixando, como obrigação para os maridos ou companheiros agressores de mulheres no lar, a doação de cestas básicas (pena inexistente na legislação brasileira), que a edição da Lei 11340/2006 tentou, por todas as formas, coibir tal abuso de brandura, vedando a 'pena de cesta básica', além de outros benefícios (art. 17 desta Lei), bem como impondo a inaplicabilidade da Lei 9.099/95” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 884).

Nesse vértice, trago recente jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE PERPETRADA NO ÂMBITO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.099/95. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 41 DA LEI 11.340/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os eminentes Ministros que o integram, à unanimidade, entenderam pela inexistência de qualquer ofensa a regra ou princípio constitucional o disposto no art. 41 da Lei Maria da Penha - que afasta a incidência do art. 89 da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher -, tornando impossível a aplicação dos institutos despenalizadores previstos no mencionado dispositivo a estes delitos. 2. A Constituição Federal, em seu art. 98, inciso I, não definiu a abrangência da expressão 'infrações de menor potencial ofensivo', isto é, coube ao legislador ordinário estabelecer o alcance do referido conceito que, considerando a maior gravidade dos crimes relacionados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, decidiu tratar de forma mais severa as referidas infrações, afastando, no art. 41 da Lei nº 11.340/06, independentemente da pena prevista, a aplicação dos institutos previstos na Lei nº 9.099/95, quais sejam, a suspensão condicional do processo e a transação penal. 3. Na hipótese vertente, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, pela prática de lesão corporal leve à sua namorada. Logo, por expressa vedação legal, não há como se aplicar o instituto da suspensão condicional do processo. 4. Ordem denegada". (STJ - HC 203374/MG HABEAS CORPUS 2011/0081715-4 – Rel. Ministro JORGE MUSSI – julg. 16/06/2011 - DJe 29/06/2011).

Portanto, afasta-se a preliminar arguida e



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

passa-se à análise do mérito recursal.

3 – Consta da denúncia que, no dia 03 de outubro de 2009, por volta das 09hs, na Rua Escócia, nº 362, nesta cidade e comarca da Capital, Stephan Schafer ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa Ana Lúcia Pecoraro Schafer, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Segundo o apurado, o réu e a vítima foram casados por treze anos, estando separados desde julho de 2007. Da união, resultou o nascimento de dois filhos menores de idade.

No dia anterior ao dos fatos, o réu foi até a residência da vítima com o intuito de buscar seus filhos e exercer seu direito de visitas. Na manhã seguinte, a vítima saía de casa para trabalhar, quando ouviu a voz de um de seus filhos, que teria voltado porque havia se esquecido de pegar um cabo de vídeo. Ela resolveu, então, ajudá-lo a procurar.

Como não conseguiram localizar referido objeto, a vítima pediu para que seu filho fosse embora, pois o pai dele, ora apelante, poderia não gostar de esperá-lo por muito tempo.

O menor seguiu os conselhos de sua mãe e foi embora. Porém, logo em seguida a vítima ouviu o réu gritar com seu filho e alguns estampidos. Acreditando que ele estaria agredindo o menor, a vítima saiu de casa e se dirigiu ao carro do réu. Quando abraçava seu filho, o apelante começou a gritar “sai do meu carro, sua louca, filha da puta” e “se você não sair do meu



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

carro eu vou entrar na sua casa”.

Não satisfeito, ele pegou o braço da vítima e o puxou para trás, ficando ela próxima da porta do veículo. Em seguida, ele passou a bater a porta do carro nas costas da vítima.

Quando percebeu que populares avistaram a cena e ameaçaram chamar a polícia, o réu resolveu parar com as agressões, entrando no veículo e saindo em disparada.

A vítima ofereceu representação criminal a fls. 10.

A denúncia foi oferecida em 14 de janeiro de 2011 (fls. 01D/03D) e recebida em 20 de janeiro de 2011 (fls. 60/61).

O apelante foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 67/68 e 85/102A).

A r. sentença foi publicada em 07 de agosto de 2012 (fls. 273), transitou em julgado para o Ministério Público em 15 de outubro de 2012 e para o assistente de acusação em 10 de novembro de 2012 (fls. 278v. e 285v.).

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 56), bem como por toda prova oral colhida nos autos.

É de se ressaltar que, muito embora realizado dias após os fatos, o laudo do exame de corpo de delito constatou, com base na ficha de atendimento técnico realizado no Hospital São Luiz, a existência de lesão leve. Ressalte-se que o prontuário médico é prova suficiente da materialidade, conforme



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

recente jurisprudência.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONTUÁRIO MÉDICO DE
ATENDIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE. VALIDADE. AUTORIA DEMONSTRADA.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE.
SÚPLICA ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. - O
prontuário médico de atendimento da vítima, descrevendo
pormenorizadamente todas as lesões por ela suportadas, é
elemento válido para a comprovação da materialidade delitiva. -
Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima
tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes,
as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar,
longe dos olhos de possíveis testemunhas". (Número do processo:
1.0324.07.056880-7/001(1). Relator: RENATO MARTINS
JACOB. Data do Julgamento: 14/01/2010. Data da Publicação:
22/02/2010) (grifo nosso).

Além disso, oportuno afirmar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito poderá ser suprido pela prova testemunhal.

Relevante mencionar decisões do Superior Tribunal de Justiça:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA (PROVA TESTEMUNHAL) CAPAZ DE SUPRIR A REFERIDA AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A ausência de laudo pericial assinado por dois peritos não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões. Isso porque o art. 158 do CPP prevê, além do exame de corpo de delito direto, o indireto, que pode ser, entre outros, exame da ficha clínica do hospital que atendeu a vítima, fotografias, filmes, atestados. Nos delitos materiais, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova (confissão, prova testemunhal, etc). Precedentes. Ordem denegada. (STJ, HC 37760 / RJ, T5 - QUINTA TURMA, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Julgado em 19/10/2004).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DUAS VÍTIMAS - LESÕES CORPORAIS: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO (MÉDICO HOSPITALAR E TESTEMUNHAL) QUE EMBASA A PRONÚNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (1) A ausência do exame de corpo de delito em situações especiais pode ser suprida por meio de outros meios de prova, tais como atestado e prontuários médicos-hospitalares, inclusive a testemunhal, como se vê do disposto nos arts. 564, III, b e 167 do CPP. (...) (TJPR - 1ª



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

C. Criminal - RSE 0465554-9 – Dois Vizinhos - Rel.: Des. Oto Luiz Sponholz - Unânime - J. 7.04.2008).

No caso em exame, constata-se que além da prova documental já mencionada, também há o depoimento da vítima perante a autoridade policial e em juízo, bem como prova testemunhal confirmando as agressões perpetradas pelo réu, o que supre a ausência do laudo pericial.

Como bem observou o Ministério Público em suas contrarrazões: *“Não há que se alegar, ainda, invalidade de tal exame, posto que realizado de forma indireta, uma vez que há previsão legal expressa permitindo sua realização. Note-se que o artigo 158, do Código de Processo Penal, trata de forma indiscriminada o exame de corpo de delito indireto”*.

Assim, não há que se falar em ausência de prova da materialidade.

De igual modo, a autoria sobressai incontroversa nas provas amealhadas ao longo da instrução.

Em Juízo, o apelante negou a prática do delito, aduzindo que no dia dos fatos, estava em casa e seu filho havia esquecido um cabo do videogame na casa da mãe, razão pela qual foram até a residência para retirá-lo. Foi de carro até o local, estacionou e ficou aguardando o filho Philip na Rua Escócia. Seu filho demorou mais de meia hora, após o que, resolveu tocar o interfone para chamá-lo. A vítima lhe disse que o filho somente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

sairia se o filho menor entrasse, embora tivesse esclarecido a ela que estavam atrasados. Após seu filho Philip entrar no carro, a vítima veio abriu a porta traseira do veículo e começou a puxar o filho menor Lucca de dentro do carro. Ele gritou assustado. Deu a volta no carro e pediu para a vítima soltar o filho para que pudesse ir embora e neste momento puxou a vítima carinhosamente pelo braço, instante em que ela gritou. Surgiu uma mulher dizendo que havia visto a agressão, gritando. Disse acreditar que tudo tenha sido uma trama, assim como os conflitos anteriores que já teve com a vítima. Esclareceu que guarda dos filhos atualmente está em seu poder. Contou, por fim, que sofre perseguição da vítima há quatro anos, sendo que esta já fez, inclusive, acusação de abuso sexual contra seu filho de cinco anos, o que foi afastado (mídia digital de fls. 189).

A vítima Ana Lúcia Pecoraro Schafer confirmou todos os fatos narrados na denúncia. Contou que no dia dos fatos, seus filhos estavam com o réu, pai deles, quando seu filho retornou para buscar um cabo de vídeo. Ele demorou um pouco porque ficou lhe ajudando a procurar a chave de seu carro e ao retornar para o carro do pai, que o aguardava, viu quando o réu gritou com ele. Correu em direção a seu filho e o abraçou para protegê-lo, ocasião em que o apelante passou a lhe agredir com a porta do carro, batendo várias vezes contra as suas costas, após o que deslocou o ombro. Após o ocorrido, o réu se evadiu e a testemunha Lucia lhe ajudou a entrar em casa. Foi orientada a procurar a polícia e lavrar a ocorrência. Afirmou que o réu era



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

agressivo com os filhos e já havia lhe agredido fisicamente antes dos fatos, além de já ter feito diversas ameaças. Disse que ele tinha o costume de bater nos filhos, razão pela qual no dia dos fatos, ficou com muito medo quando ouviu os gritos. Acreditou que ele fosse bater em seu filho. A testemunha dos fatos foi uma professora que costumava parar o carro no local. Já havia visto essa moça antes, mas não se tratava de uma amiga. Contou que o apelante lhe acusava de usar o pretexto da “violência doméstica” para alienação parental. Atualmente a guarda de seus filhos está com o apelante. Disse que após os fatos, foi até o Pronto Socorro do Hospital São Luiz para ser atendida. Ficou 15 dias com uma tipoia e as lesões foram atestadas. Os prontuários médicos foram entregues na delegacia, tendo sido orientada pelo delegado a levar toda a documentação ao IML, porque se tratava de lesão interna e o exame simples do IML poderia não atestar a gravidade (fls. 189).

No que pertine ao depoimento da vítima, a jurisprudência dominante é tranquila quanto à sua validade:

PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DELITO DE AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Nos crimes praticados dentro do ambiente domiciliar tipificados pela Lei Maria da Penha a palavra da vítima assume extrema importância, ainda mais quando confirmada por outros indícios veementes, se apresentando suficiente ao decreto condenatório, independente da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

negativa de autoria do acusado, especialmente porque praticados normalmente na clandestinidade, ausentes quaisquer testemunhas presenciais. (APELAÇÃO Nº 1.0177.07.007667-0/001(1)- TJMG-Rel. Des. Pedro Vergara- DJ 03-02-2010).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Lúcia Machado Sarasua que afirmou ter presenciado os fatos. Disse que tudo ocorreu num sábado pela manhã, horário em que dá aulas de espanhol numa escola próxima ao local dos fatos. Viu quando um carro preto estava estacionado próximo à calçada e dele saiu um homem muito alto e também uma criança. O homem falava muito alto e dava muita bronca, mandando que a criança entrasse rápido no carro. Então, nesse momento, apareceu a vítima, a quem conhecia de vista, porque leciona na mesma escola há oito anos e sempre para o seu carro no mesmo local, naquela rua. A vítima veio chorando e dizia: “para, para” e entrou no carro e se debruçou. O apelante passou a xingá-la, proferindo palavras de baixo calão, aos gritos. Ele dizia “louca”, “filha da puta”, etc. Somente nesta ocasião, viu que a vítima abraçava o filho, que chorava dentro do carro. Em seguida, o réu entrou no carro e saiu com uma bolsa na mão, dizendo: “aqui está sua bolsa.” Ele dizia: “pega aqui, sua louca”. Nesse momento, ele torceu o braço da vítima para trás, com violência e passou a jogar a porta do carro contra ela, com muita violência. Resolveu interceder e gritou: “que bonito, batendo em mulher”. Levou a vítima para dentro de casa, com a ajuda de uma empregada, enquanto o réu arrancou com o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

carro. Contou que a vítima estava “arrebentada”, muito machucada e a encorajou a ir ao Hospital e a fazer um boletim de ocorrência. Ficou revoltada e indignada com o que tinha visto. Deixou seu nome completo, endereço e telefone com a vítima, para ser testemunha caso ela precisasse. Contou que um moço que cuida dos carros na rua também tentou ajudar. Não presenciou o pai agredindo o filho, mas viu que ele estava muito alterado, tendo, inclusive, batido com violência contra o portão. Viu quando a vítima abriu a porta para abraçar o filho e, em nenhum momento, ela partiu na direção do acusado (mídia digital de fls. 189).

A testemunha do Juízo Agnaldo da Silva Santos também confirmou os fatos narrados pela vítima asseverando que é vigilante da rua e todos que ali moram contribuem com o seu pagamento, inclusive a vítima. Recordou-se do sábado em que o apelante foi até a casa da vítima com os filhos, porque um deles havia esquecido um cabo. O réu e o outro filho ficaram aguardando no carro. A vítima saiu de casa e veio no carro para dar um abraço no filho menor. Nesse momento viu o réu batendo com a porta na vítima, prensando-a. Saiu da guarita e foi em direção a eles com o intuito de apartar. Não viu se o apelante torceu o braço da vítima. O filho da vítima não demorou para voltar para o carro. Nesse momento, o apelante ficou agitado e passou a gritar com os meninos. A vítima veio em direção ao carro e tudo começou. Não viu a torção no braço da vítima. Afirmou que teve que puxar o réu para ele sair. A testemunha Lúcia apareceu e passou a xingá-lo, dizendo que havia visto a agressão. Em seguida, o



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

apelante saiu com o carro. A testemunha Lúcia ajudou a vítima a ser socorrida, porque ela estava machucada, com o braço torcido. Relatou que o réu já havia invadido umas duas ou três vezes a casa da vítima. Ela sempre pedia para que a polícia fosse chamada quando ele invadisse. Em uma das oportunidades a polícia foi acionada e eles disseram que ele não podia fazer aquilo, porque havia uma ordem judicial que o impedia. No dia dos fatos, mesmo com sua intervenção, o apelante não soltava a vítima. Afirmou que não queria depor para não ficar mal nem com a vítima, nem com o réu (mídia digital de fls. 189).

A testemunha de defesa Philip Pecoraro Schafer, filho do casal, contou que no dia dos fatos estava com seu irmão Lucca e o pai. Dirigiram-se até a casa de sua mãe porque havia esquecido um carregador. Acreditava que sua mãe estivesse viajando e que somente a empregada estaria no local. Entrou na casa, pegou o carregador e ajudou a mãe a procurar as chaves que ela havia perdido. Saiu e entrou no carro. Nesse momento, sua mãe foi em direção ao veículo, abriu a porta do carro e abraçou seu irmão Lucca, que começou a brigar. Estavam atrasados para algum almoço e seu pai falou para entrar logo no veículo, nesse momento seu irmão gritou, mas não soube dizer por qual motivo. Acredita que ele tenha se assustado. Depois disso, não se lembrava mais de nada. Não se recorda de ter presenciado a agressão. Afirmou já ter presenciado brigas entre seus pais, mas sem violência. Recordou-se que seu pai desceu do carro, foi em direção à vítima, pediu licença e fechou a porta do carro, antes de deixar o local. Disse, por fim, que



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

uma moça que estava na esquina veio correndo e dizia: “eu vi, eu vi, eu vi” (mídia digital de fls. 189).

Veronika Spindeldreher afirmou ser companheira do réu há quatro anos e não presenciou o ocorrido. Afirmou que ele não é uma pessoa violenta e nem desequilibrado. Teve contato com a vítima apenas por telefone para tentar conversar sobre as crianças, mas não foi bom, porque ela começou a fazer comentários sobre o comportamento do réu, demonstrando revolta. Nunca presenciou o apelante xingando sua ex-mulher (mídia digital de fls. 189).

A testemunha Lidia Rosalina Folgueira Castro, Psicóloga Judiciária, afirmou ter participado da avaliação do caso no âmbito da Vara de Família. Disse que naquela ocasião, havia relatos de violência de ambos os lados. Asseverou não ter condições de avaliar se havia ou não intenção deliberada da vítima em prejudicar o réu. Na época, no papel de Perita da Vara de Família, sugeriu a guarda compartilhada, uma vez que seu interesse é resguardar o interesse das crianças e, em casos muito litigiosos, essa hipótese pode ser o melhor caminho. Consignou, por fim, que não acredita que o réu tenha traços de violência com relação aos filhos (mídia digital de fls. 189).

Assim vista a prova, conclui-se que condenação era mesmo de rigor.

Portanto, contrariamente ao alegado pela defesa, as provas trazidas aos autos, quais sejam, as declarações da vítima, das testemunhas presenciais, assim como o laudo de exame



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

de corpo de delito, são suficientes para a condenação nos exatos termos da sentença de primeira instância, não havendo se falar, portanto, em absolvição.

Com efeito, as alegações do apelante são insubsistentes, porquanto a r. sentença examinou minuciosamente todos os pontos apresentados pela acusação e pela defesa, contendo conclusões coerentes com a realidade dos fatos, e não merece ser reparada.

A palavra da vítima nos crimes como os ora analisados que se dão, na maioria das vezes, às escondidas, dentro das residências e longe de testemunhas, tem valor probatório relevante, sobretudo, quando corroboradas por outros indícios, como no caso, pelo depoimento das testemunhas presenciais.

Neste sentido:

“PENAL - AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBANTE -ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Estando a autoria e materialidade comprovadas pela palavra da vítima que nestes casos possui especial valor probante, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (TJMG, Ap. Crim. 1.0525.07.105380-1, Rel. Pedro Vergara, Julgado em 21/07/2009, Publicado em 10/08/2009).

Sua versão se encontra corroborada pelo



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

depoimento das testemunhas Lucia e Agnaldo, que confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como a agressão sofrida pela vítima.

Nada há nos autos a indicar que tais testemunhas tivessem interesse em prejudicar um inocente. Assim, não se desincumbiu a d. Defesa do ônus probatório que lhe incumbia a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Fernando da Costa Tourinho Filho, igualmente, salienta o questionamento da valia da prova testemunhal, todavia, preleciona:

"A prova testemunhal, principalmente no Processo Penal, é de valor extraordinário, pois, dificilmente, e só em hipótese excepcionais, provam-se as infrações com outros elementos de prova. Comumente, as infrações penais só podem ser provadas, em juízo, por pessoas que assistiram ao fato ou dele tiveram conhecimento" (Processo penal 3o v 16a ed. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 263) No parágrafo seguinte explica "Assim, a prova testemunhal é uma necessidade, e nela reside seu fundamento" (Ob cit, p 263).

Por tudo isso, inviável a absolvição pretendida pela d. Defesa.

As penas estabelecidas também não merecem reparos, uma vez que estabelecida no mínimo legal, isto é, em 03 meses de detenção, assim permanecendo inalterada, ante a ausência de outras circunstâncias.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Nenhum reparo merece também o regime aberto estabelecido, já que é o mais benéfico ao apelante.

Inviável, no entanto, o pedido defensivo de substituição da carcerária por restritiva de direitos.

Como bem consignou a d. Juíza *a quo*, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto o artigo 44 do Código Penal veda expressamente a substituição da carcerária por restritiva de direitos, quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorreu no caso concreto. Nenhum reparo, portanto, deve ser feito a r. sentença de Primeiro Grau também quanto a este tópico.

Por outro lado, observo ser cabível a suspensão condicional da pena, prevista nos artigos 77 c/c artigo 78, § 1º, do Código Penal, conforme se vê:

Dispõe o art. 77 do Código Penal:

Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) anos e 4 (quatro) anos, desde que:

I- o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III- Não seja indicada ou cabível a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Por sua vez, artigo 78, § 1º, do CP, prevê que:

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48).

Segundo consta dos autos, o apelante preenche os requisitos do artigo 77, I a III, do Código Penal, porquanto primário, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, a pena aplicada foi inferior a 02 (dois) anos, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível *in casu* por ter o agente agido mediante violência contra a pessoa (art. 44, I, CP), de forma que, reunindo os requisitos objetivos e subjetivos, tem direito ao benefício da suspensão condicional da pena.

Assim, na forma do artigo 159, § 2º, da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Lei de Execuções Penais, deve ser concedido ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, em condições a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

A propósito:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, atestado médico, auto de exame de corpo de delito e prova oral, que, de certa forma, confirma as declarações da vítima. Legítima defesa e diminuição da pena por ser o delito cometido mediante relevante valor moral ou social, logo em seguida à injusta provocação da vítima - Afastamento. Não comprovação. Substituição da pena corporal por restrição de direitos - Impossibilidade, ante o enunciado do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Suspensão condicional da pena - Possibilidade, ante a presença dos requisitos legais. Apelo parcialmente provido. (TJRS; ACr 70029748654; Panambi; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira; Julg. 03/06/2009; DOERS 22/06/2009; Pág. 159).

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. (1). Tratando-se de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do que dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal. (2) caberá ao juízo de primeiro grau, além de fixar as condições para cumprimento da pena no regime aberto, examinar a possibilidade de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Ap Crime 0571480-3; São José dos Pinhais; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oto Luiz Sponholz; DJPR 15/10/2009; Pág. 291).

Destarte, concedo o *sursis* pelo período de prova de 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo juízo da execução em audiência admonitória (art. 77 e seguintes, do CP).

4 – Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto por Stephan Schafer apenas para conceder o *sursis* pelo prazo de dois anos, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Paulo Antonio **Rossi**

Relator